

Clase 1

Contratos

I.- El concepto de contrato:

Art. 1137: *“Habrá contrato cuando varias personas se ponen de acuerdo sobre una declaración de voluntad común destinada a reglar sus derechos”*

De la propia definición del código civil plantea una característica fundamental del contrato: Implica un acuerdo de voluntades, principio de la que se derivan las siguientes consecuencias:

1.- Es necesaria la concurrencia de dos o mas personas: El ordenamiento argentino, a diferencias de otros regímenes como el alemán, no prevé la existencia de un auto contrato: Es, por tanto, condición esencial la existencia de dos o mas personas para que exista contrato.

2.- Cada una de estas personas debe realizar una manifestación de voluntad: Cada una de estas manifestaciones de voluntad por separado constituye un acto jurídico con las características y requisitos vistos en la ficha anterior.

3.- Estas manifestaciones deben ser concurrentes: Cada una de las personas debe realizar una manifestación de voluntad tendiente a la generación de un contrato determinado, ya sea realizando una oferta o aceptándola. Esta premisa que en principio parece redundante adquiere relevancia en los casos en que por error o dolo alguna de las partes consiente un negocio jurídico diferente al aceptado por la otra, hecho que puede derivar en conflictos judiciales.

4.- Ambas manifestaciones deben tender a la generación o modificación de derechos y obligaciones: Algunos autores (vg Guillermo Borda) han criticado la redacción del art. 1137 toda vez que según el mismo podría considerarse

contrato manifestaciones tendientes no a generar sino extinguir a los derechos y obligaciones. Este último negocio jurídico, si bien guarda similitudes con el objeto del presente apunte, constituye según la doctrina un instituto diferente al que se denomina *distracto*.

II.- Evolución Histórica del contrato:

La evolución histórica resulta importante en tanto en cuanto permite analizar la existencia de una relación entre las formas contractuales, las relaciones de poder y la circulación de bienes y servicios a la que estos dan cobertura jurídica.

Originariamente y según la concepción romana, la voluntad de las partes no resultaba el elemento esencial del instituto: La forma y la existencia de un reconocimiento del negocio por parte del estado constituían las condiciones necesarias para la existencia de una convención exigible: Era el príncipe quien otorgaba la obligatoriedad a los acuerdos, los que debían adecuarse a tipos determinados y cumplir con las formalidades establecidas para los mismos. Recién en tiempos del emperador bizantino Justiano se previó la existencia de una acción judicial a los efectos de forzar el cumplimiento de los acuerdos entre las partes que no estuvieran previstos por el ordenamiento, pero siempre y cuando una de las partes haya realizado la prestación obligada, circunstancia que hace pensar que el fundamento estribaría más en una cuestión de equidad que de respeto de la voluntad de las partes.

Hubo que esperar hasta la revolución francesa para que la voluntad tuviera capacidad de generar derechos y obligaciones. Históricamente, este fenómeno encuentra su base en el desplazamiento del poder económico de los estados centrales o feudales hacia las burguesías comerciales, con la consiguiente intención de estas últimas de evitar el control gubernamental de sus transacciones.

En la concepción francesa, la voluntad constituye la base y el fundamento de la obligación derivada de los contratos. Si los hombres son naturalmente libres e iguales, deben tener derecho a determinar sus relaciones personales sin intervención del estado, con excepción de los casos de incumplimiento. En esta visión, la función del derecho se limita a dar fuerza

obligatoria a lo que las partes libremente acuerdan, existiendo simplemente como mecanismo de cumplimiento forzoso en los casos de obligados reticentes.

Sin embargo, dicha concepción conlleva una contradicción fundamental en tanto confunde la igualdad jurídica con la económica, otorgando similar capacidad negocial a sujetos materialmente disímiles. Dicho de otro modo: Si la igualdad puede sostenerse como posibles entre dos comerciantes del siglo XVIII, es indudablemente insostenible en una economía de masas, en la que el sujeto se encuentra frente a operadores jurídicos con capacidad económica de imponer sus propias condiciones al contrato.

En el mismo sentido el simple acuerdo de voluntades choca con una realidad básica del siglo XIX y más aun en el siglo XX: los grandes conglomerados urbanos hacen imposible el conocimiento personal de cada una de las transacciones realizadas, circunstancia que impide la seguridad jurídica respecto a las operaciones, lo que deriva en la posibilidad cierta de perjuicios de terceros, quienes son sorprendidos en su buena fe al adquirir bienes que ya fueron vendidos a otras personas con anterioridad (a veces muchas veces).

Por lo tanto, en la actualidad se produce una vuelta a las soluciones del pasado en cuanto a la intervención estatal, aunque en este caso la finalidad es diferente: No se busca el control del ciclo económico por parte del estado sino la protección de los terceros y las partes más débiles de la relación contractual, manteniendo el estado un papel tutelar, limitando la regla general de la autonomía de la voluntad en los casos en que de ella puedan derivarse resultados disvaliosos.

Aplicación del principio moderno de la intervención estatal: La intervención estatal se manifiesta principalmente mediante tres fenómenos legales: El dirigismo contractual, las nuevas formas del contrato y la posibilidad de revisión judicial de lo acordado.

1.- El dirigismo contractual: Tal como vimos anteriormente la posibilidad de dejar librado a la libre voluntad de las partes la celebración de ciertos contratos puede conllevar la existencia de abusos de la parte con mayor capacidad negocial. Es por ello que el estado, en los casos en que se encuentra involucrado el interés público, limita la capacidad de disposición de los contratantes. De esta forma, verbigracia, el contrato de trabajo se encuentra

legislado en forma detallada en lo que respecta al cumplimiento de las tareas, el cobro de los salarios, límites a los horarios, etc. Dichos límites tienen como base la protección de la parte más débil, por lo que cualquier convención que supere el mínimo impuesto es válida: No se trata de forzar un contenido sino de asegurar un *piso* de derechos que las partes, de así quererlo pueden superar.

2.- Las nuevas formas contractuales: La estructura clásica del contrato implicaba el libre acuerdo de voluntades celebrado entre particulares. Sin embargo, en la actualidad pueden encontrarse formas de perfeccionamiento del contrato donde uno de estos elementos se encuentra modificado.

Los contratos de adhesión son una forma contractual en la cual, las cláusulas se encuentran predispuestas por una de la partes, limitándose la otra a aceptar o rechazar la convención. Este tipo de contratos, que se encuentra ligado normalmente a economías de masas, conlleva una forma de interpretación particular, atento la incapacidad de una de las partes de modificarlo.

Los convenios colectivos modifican sustancialmente la concepción de contrato, en razón de su carácter público y su alcance más allá de los celebrantes. Esta forma de contrato nace con la representación gremial e implica una negociación de carácter general entre la organización sindical y el empresariado, convenio que una vez celebrado es aplicable a todas las relaciones laborales de la especialidad, hayan participado en la vida gremial o no.

Muchos autores han negado el carácter contractual al convenio colectivo, argumentando la ingerencia del derecho público lo aparta del concepto básico. En este sentido, debe tenerse en cuenta que en nuestro país, los convenios deben ser homologados por el ministerio de trabajo, circunstancia que lo aleja aún más del contrato en sentido clásico, habida cuenta que es la recepción estatal y no el acuerdo entre las partes lo que le da la fuerza obligatoria.

Los contratos forzosos son la forma más extrema de limitación. En esta hipótesis se elimina el consentimiento en forma casi total, dejando elementos accesorios del contrato a disposición del contratante. Así, las leyes de agio obligaron a los comerciantes a vender sus mercaderías a un precio prefijado, pudiendo elegirse sólo la persona del co contratante. En estos casos no

encontramos con excepciones basadas en el interés público, lo que permite al estado limitar, aunque sea provisionalmente, ciertas libertades económicas en pos del bien común.

III.- Clasificación de los contratos:

Es necesaria, antes proseguir con este tema, una ponderación previa respecto a las clasificaciones, toda vez que las mismas constituyen un modelo arbitrario de la realidad, dependiente casi en forma exclusiva de la voluntad del doctrinario. Sin embargo, si bien la elección de los caracteres definitorios de cada categoría pueden llegar a ser parciales, no por ello dejan de ser ciertos y nos permiten analizar la realidad contractual en forma organizada, aunque siempre teniendo en cuenta que se trata de modelos ideales, pudiendo un convenio determinado presentar características de mas de una de las categorías.

1.- Contratos Bilaterales y Unilaterales: Son convenios bilaterales aquellos en los cuales el acto jurídico genera obligaciones en ambas partes de la relación jurídica. En tal sentido, ambos contratantes se transforman a la vez en acreedor y deudor. Tal es el caso de la compraventa donde, por ejemplo, el vendedor es acreedor de la entrega de dinero, mientras que es deudor respecto de la entrega de la cosa. En cambio, en los unilaterales la relación sucede en un solo sentido, no existiendo esta interdependencia de prestaciones (vg. la donación)

Esta circunstancia tiene particular importancia al momento de analizar la excepción de incumplimiento y el pacto comisorio

2.- Contratos gratuitos y onerosos: En este caso el factor determinante es la existencia o no de contraprestaciones económicamente apreciables. Comúnmente se confunde esta categoría con la anterior, pero debe tenerse en cuenta que un contrato puede generar obligaciones a las partes que no sean apreciables en dinero, por lo que el contrato seguiría siendo bilateral pero no oneroso. Tal es el caso de los contratos de servicios de correo vía web, donde el usuario acepta obligaciones de abstención (vg el correo no puede ser usado para realizar spam) sin generar un intercambio económico con el sitio. Asimismo debe tenerse en cuenta que un contrato oneroso no siempre se expresa en sumas de dinero: basta que las contraprestaciones sean

apreciables económicamente para ser oneroso: Por ejemplo, en la permuta no existe intercambio de dinero, sin embargo es contrato oneroso toda vez que los bienes que se intercambian tienen un valor pecuniario.

3.- Contratos principales y accesorios: Son contratos principales aquellos que cuyo negocio jurídico se basta a sí mismo, sin necesidad de una convención adicional que les de sentido. En cambio, el contrato accesorio tiene un claro sentido instrumental, estando subordinado a la suerte de un principal. Tal es el caso de la fianza, contrato de garantía, cuya existencia depende de un convenio principal (vg. un contrato de alquiler), al que sirve de garantía.

4.- Contratos nominados e innominados: Cuando analizamos la evolución histórica del instituto, mencionamos que el principio de libertad contractual permitía a las partes fijar las cláusulas que estas entendían mejor se ajustaban al negocio que pretendían realizar. Sin embargo existen algunos contratos que, mas allá de esta potestad de las partes, se encuentran legislados en el ordenamiento, constituyendo estos la categoría de nominados.

Sin embargo la existencia de una regulación legal de un convenio no necesariamente limita la libertad de las partes al contratar. En este sentido es necesario analizar si las normas adoptadas tienen un sentido imperativo o meramente supletorio. Si estamos frente a una norma en sentido imperativo, las partes no pueden apartarse de lo dispuesto, mientras que las normas en sentido supletorio constituyen una regulación por defecto tendiente a suplir el silencio de la parte respecto de una cláusula usual del convenio: En tal sentido las partes tienen la facultad de convenir algo distinto a lo legislado, en cuyo caso la norma queda sin efecto.

IV.- Formación del contrato: Si definimos al contrato como un acuerdo de voluntades, es una consecuencia necesaria que para su formación será condición necesaria la concurrencia de por lo menos dos voluntades: Una primera que proponga el negocio jurídico y una segunda que lo acepte.

Podemos definir oferta como la proposición unilateral que una de las partes dirige a la otra para celebrar un contrato.

La regulación jurídica de la oferta en el código civil argentino (art. 1148) requiere la existencia de una propuesta que contenga todos los elementos del negocio jurídico, incluido a los sujetos a los que se encuentra dirigido: la

propuesta de contrato realizada a personas indeterminadas no constituye *per se* una oferta de contrato sino simplemente una invitación a ofertar a los hipotéticos destinatarios. Esta característica lo diferencia de la regulación establecida para los casos de contratos de consumo (vg. la publicidad de ofertas de un supermercado), los cuales constituyen una oferta obligatoria para quien la realiza. El elemento que separa ambas regulaciones es la relación de consumo, entendiendo a esta como aquella establecida entre un consumidor final de un producto o servicio determinado y un comerciante.

Respecto a la duración de la oferta, nuestro código establece que la misma es revocable en cualquier momento antes de la aceptación, excepto en los casos en que la parte expresamente haya limitado esta posibilidad al momento de la formulación. Excepcionalmente y en los casos en que la otra parte haya aceptado el contrato desconociendo la retractación y a tal fin se haya realizado gastos, esta tendrá derecho a resarcirlos pero no reclamar el cumplimiento del contrato.

Como contrapartida, la aceptación constituye el acto que consuma el acuerdo voluntades. Para que produzca su efecto propio es necesario que la misma sea lisa y llana, es decir que no modifique en modo alguno los términos de la oferta. Si ello no sucede no estaremos frente a una aceptación sino a una nueva oferta, la cual deberá ser aceptada por el anterior oferente.

Asimismo es necesaria que la aceptación sea realizada en tiempo oportuno, antes de la retractación del oferente. Esto tiene particular importancia en los contratos entre ausentes en los que el envío de aceptación y su recepción pueden estar separados entre sí por lapsos importantes. Por tanto, es necesario precisar que momento se entiende que la aceptación se realizó. En tal sentido la doctrina distingue cuatro soluciones legislativas posibles dependiendo si entendemos que la aceptación se realizó al momento de la declaración de aceptación, de su envío, de su recepción por parte del oferente o simplemente cuando este último tuvo conocimiento de la aceptación.

Como regla general y respecto a las relaciones regidas por el código civil, nuestro ordenamiento en el art. 1154 referido cuerpo legal define la cuestión estableciendo que el contrato se perfecciona al momento del envío de la aceptación. Sin embargo, y como excepción, el aceptante tiene derecho a

retractarse hasta tanto el oferente no haya tenido conocimiento de la primera declaración de voluntad (art. 1155).

V.- Elementos de los contratos

1.- Los sujetos: Toda relación jurídica implica necesariamente la existencia de sujetos de derecho, ya sea de existencia física o legal (sociedades, fundaciones, cooperativas o demás casos en que la ley otorga capacidad para ser titular de derechos y obligaciones). Respecto a una relación jurídica determinada podemos clasificar a los sujetos en:

La Partes: Las partes de una relación jurídica son aquellas que por si o por intermedio de un representante, se han obligado a cumplir cierta conducta o son titulares de un determinado derecho. Debe tenerse en cuenta que, en los casos de actos jurídicos, debe diferenciarse entre las partes y los firmantes u otorgantes del acto: Si bien en la mayoría de los casos ambas figuras coinciden en la misma persona, no necesariamente esto es así, como lo demuestra la figura del mandatario o representante ya sea legal o convencional.

Asimismo se considera partes a los sucesores universales de una persona fallecida. Esto es así porque para nuestro ordenamiento los sucesores de una persona fallecida continúan el lugar jurídico del causante. Sin embargo esta regla tiene excepciones:

1.- En los casos en que la obligación se hubiera realizado teniendo en cuenta las características personales del fallecido. Tal es el caso de la mayoría de las locaciones de obra, particular cuando el encargado de la obra contaba con cualidades particulares que eran definitorias del contrato (ej. El encargo de una obra a un pintor)

2.- En los casos que las partes al momento de contratar hayan definido que al muerte de una de ellas resuelve el contrato. En tal caso, los sucesores, si bien continúan la persona del causante, no esta obligados a prestación alguna ya que la misma dejó de existir con el fallecimiento.

3.- Los casos que se acepte la sucesión con el llamado beneficio de inventario. En tal caso los patrimonios del sucesores y el causante no se mezclan y se evita la confusión entre los mismos.

Los terceros: Desde un concepto amplio, puede decirse que un tercero es todo aquel que no es parte de una relación jurídica. Como principio general, los actos realizados por las partes no tiene efectos contra los terceros, salvo en el caso de transmisión derechos reales, los cuales son oponibles contra cualquier persona, haya o no participado en el acto de cuestión.

2.- La Causa:

La palabra causa tiene en el derecho dos acepciones diferentes: La primera refiere al **hecho respecto del cual derivan las obligaciones**, ya sean estas un **hecho ilícito, la voluntad de las partes o simplemente la misma ley.**

La segunda, y es la que nos interesa a los efectos de este apunte, **significa el fin que las partes se propusieron al contratar.** Según la doctrina más difundida, la causa es el fin inmediato y determinante que las partes han tenido al contratar, es la razón directa y concreta que las partes para la celebración del acto y atento ello, no puede ser ignorada por la contraparte.

Debe igualmente diferenciarse la causa de los meros motivos que las partes tuvieron al contratar. La primera son los fines inmediatos que una persona tuvo al celebrar un acto, la segunda, en cambio, son las motivaciones psicológicas que llevaron a las partes a hacerlo, las cuales no tienen efectos jurídicos inmediatos. Así, por ejemplo, en un contrato de compraventa de inmuebles, la causa es para el vendedor es el pago del precio, en cambio si los motivos puede ser la compra de un inmueble mas grande. Para el derecho, la satisfacción de este motivo ulterior carece de efectos: compre o no el segundo inmueble, la operación es válida.

La principal regulación de la causa, esta dada por los art. 500 y 502 del código civil. Ellos regulan los problemas derivados de la nulidad, o falsedad de la causa y sus efectos jurídicos. El art. 500 establece una presunción de existencia de la causa, aun en los casos en que la misma no este expresada al momento de la obligación. Esto obedece al hecho que por razones de seguridad jurídicas la validez de los negocios jurídicos se presume, siendo carga de quien plantea su nulidad la prueba de dichos extremos.

Sin embargo, puede ser la causa no existe, sea contraria a derecho o existiendo la misma sea falsa. En los dos primeros casos nos encontramos con

una relación jurídica sin causa, la cual debe reputarse nula (art. 502). Sin embargo, en el último caso, vemos que si bien la causa manifestada es falsa, puede ocultar otra válida. Tal es el caso de los actos simulados, donde las partes conscientemente crean una causa falsa, normalmente en perjuicio de sus acreedores u otro tercero, para ocultar otra causa real. En tales casos, el ordenamiento sostiene que si la causa real es válida, el acto simulado se mantiene. Esto es de particular importancia respecto a los terceros, toda vez que pueden oponer el acto a los simuladores, si así les conviene.

3.- El Objeto: El concepto de objeto refiere a la cosa o hechos sobre la cual recae la obligación contraída. En otros términos se trata de la prestación debida.

El objeto constituye un elemento fundamental de la relación jurídica, toda vez que no puede entenderse una relación obligacional donde nadie tenga obligación de nada. Sin embargo, no todo objeto es válido, debiendo cumplir lo normado por el art. 953 del Código Civil, el cual expresa:

El objeto de los actos jurídicos deben ser cosas que estén en el comercio o que por un motivo especial no se hubiese prohibido que sean objeto de un acto jurídico o hechos que no sean imposibles, ilícitos contrarios a las buenas costumbres o prohibidos por las leyes o que se opongan a la libertad de las acciones o de la conciencia o que perjudiquen los derechos de un tercero. Los actos jurídicos que no sean conforme a esta disposición son nulos como si no tuviesen objeto.

En función del texto del artículo, vemos que el objeto debe cumplir con tres condiciones básicas:

1.- Debe ser Posible: Esta posibilidad física de realizar la prestación debe ser absoluta y no relativa al contratante. Por ejemplo, la obligación de construir una catedral o pintar un retrato puede resultar imposible para una persona no entrenada, pero la obligación sigue siendo válida entre las partes y su incumplimiento conlleva sanciones. En cambio, la prestación “saltar un edificio” es físicamente imposible y debe reputarse nula.

2.- Debe ser Lícito: Todo objeto contrario al ordenamiento es nulo. Ello obedece a que el ordenamiento no puede otorgar validez a un acto que niega su vigencia, so pena de caer en un contrasentido lógico.

3.- Debe ser conforme a la moral y las buenas costumbres: Este concepto constituye un standard jurídico, el cual debe evaluarse en el caso concreto. Sin embargo, es conteste la jurisprudencia en calificar estas actividades como contrarias a la moral: La locación de inmuebles para casas de citas, los pactos de retroventa de automotores como garantía de un préstamo¹, los intereses usuarios.

Respecto a los efectos debe tenerse en cuenta si la prestación constituye una parte esencial de la convención o si, por ejemplo en los casos de pactos de retroventa o intereses, estamos frente a un accesorio. Normalmente en el primer caso se decreta la nulidad de toda la convención, mientras que en el segundo, simplemente afecta a la cláusula, dejando la relación jurídica vigente.

VI.- Efectos de los contratos. La excepción de incumplimiento y el pacto comisorio

a.- Principios Generales:

El principal efecto de la celebración de un contrato es que las partes quedan obligadas al cumplimiento de las cláusulas establecidas en el mismo. Es así que el artículo 1197 de código civil establece que las convenciones hechas en los contratos forman para las partes una regla a la cual deben someterse como a la ley misma.

El concepto de parte en el sentido jurídico del término debe diferenciarse de los signatarios del acto jurídico. Este último término se emplea para designar a las personas que aparecen celebrando el acto y manifestando su voluntad mediante la firma. Sin embargo no necesariamente ello los transforma en parte del contrato, toda vez que podemos estar frente a un representante de la parte como puede ser un mandatario o el representante legal de la misma.

Respecto de las personas que no revistan la condición de parte, existe un viejo principio jurídico que del derecho romano que establece que los

¹ Es particularmente común, en los casos de prestamos usurarios, la venta al prestamista de una automotor o inmueble como garantía con el agregado de una cláusula de devolución al deudor en caso de cumplimiento y de esta forma evitar la ejecución de la deuda o su discusión judicial. Esta convención accesorio es conocido como pacto de retroventa

contratos no obligan sino a las partes y no tienen efectos respecto de los terceros. Sin embargo debe tenerse en cuenta que esta regla tiene excepciones, a tal punto que algunos autores se preguntan si puede hablarse realmente de un principio general.

En primer lugar se considera que los sucesores universales de uno de los contratantes como parte. Esto es así, atento que para el derecho argentino el sucesor a título universal continúa la persona del fallecido, adquiriendo todos los derechos y obligaciones de este último. Sin embargo, esta ficción legal se encuentra en la actualidad limitado por el llamado beneficio de inventario, instituto del derecho sucesorio que limita la responsabilidad del heredero respecto de las deudas del causante al patrimonio heredado. De esta forma, el heredero se transforma en un tercero por lo menos respecto los bienes de su propio activo, los cuales no pueden ser ejecutados por los acreedores del causante.

De la misma manera, debe tenerse en cuenta que las partes pueden haber previsto la disolución de las obligaciones en caso de muerte, en cuyo caso tampoco estaríamos frente a una continuación de las mismas. Por último, es necesario señalar que en los casos en que las convenciones se hayan realizado teniendo en cuenta las circunstancias personales de los contratantes, las mismas no se trasladan a sus herederos.

En segundo lugar, es posible que las partes hayan convenido cláusulas a favor de terceros. Tal es el caso, por ejemplo de las indemnizaciones derivadas de los seguros de vida, la cual es pagada al beneficiario de la póliza y no al contratante o sus herederos. En tal caso nos encontramos ante varias relaciones jurídicas diferentes: Una entre los contratantes, una segunda que se establece entre el estipulante y el beneficiario y una tercera, de carácter directo, entre el beneficiario y el obligado al pago. Debe tenerse en cuenta que en esta hipótesis el beneficiario no participó en momento alguno en la negociación o redacción del acuerdo.

b.- Límites a la obligatoriedad de los contratos: Tal como veníamos diciendo al hablar de evolución histórica, la autonomía de la voluntad como fundamento de la obligatoriedad de los contratos encuentra su límite en la función social del instituto, por ende la capacidad de obligarse de los

contratantes tiene por contrapartida un límite establecido. En este sentido, los contratos carecerán de fuerza obligatoria:

- 1.- Si son contrarios a leyes de orden público: En estos casos englobamos asimismo las cláusulas imperativas de los contratos nominados.
- 2.- Si son contrarias al moral. El art. 953 del código civil establece que las convenciones no pueden ser contrarias a la moral. En tal caso estamos frente a un estándar jurídico que ha ido evolucionando con el correr del tiempo, englobando no solo cuestiones de índole sexual (vg. contratos sobre casas de tolerancia) sino cláusulas de contenido económico, las cuales implicaban un aprovechamiento del estado de necesidad de uno de los contratantes. Tal es el caso de las cláusulas usuarias o penales exorbitantes.
- 3.- Por último, debe tenerse en cuenta que el 1198 del Cod. Civil establece que los contratos deben ejecutarse y celebrarse de acuerdo a las reglas de la buena fe. Este principio conlleva necesariamente la limitación de las partes quienes no pueden lucrar con la inexperiencia o necesidad de la otra parte, so pena de violar este principio. En el mismo sentido, debe tenerse en cuenta que en un aspecto dinámico las partes pueden apartarse de lo establecido en la convención cuando circunstancias sobrevinientes modifiquen en modo sustancial la ecuación económica del arreglo.

c.- La excepción de incumplimiento: La excepción de incumplimiento implica la potestad jurídica de una de las partes a negarse a cumplir el requerimiento de la otra, en los casos en que esta se encuentre en mora (no haya cumplido) las obligaciones que, derivadas del contrato tenía a su cargo

El origen de la excepción se remota al derecho romano, ordenamiento que otorgaba a los demandados una excepción de carácter procesal destinada a evitar la prosecución de un juicio de incumplimiento de contrato en los casos en que la demandante no haya cumplido las obligaciones a su cargo.

En la actualidad esta excepción encuentra su base en la existencia de una relación de reciprocidad entre las partes de un contrato bilateral: Al existir un equilibrio entre las prestaciones, es necesario que la parte que pretenda la ejecución de las obligaciones que le son debidas no puede estar constituido en mora. Por lo tanto los requisitos para la procedencia de la excepción de incumplimiento son las siguientes:

- 1.- Que se trate de un contrato bilateral

2.- Que las obligaciones de sean exigibles: En este sentido si las mismas se encuentran sujetas a plazo o condición y este no se ha cumplido, no es posible plantear su incumplimiento toda vez que en realidad todavía no es obligatorio el pago.

3.- Que la requirente haya dejado de cumplir total o parcialmente sus obligaciones: En este caso no es posible hacer distingos entre una y otra, sin embargo es necesario puntualizar que debe guardarse un equilibrio entre el incumplimiento y la obligación a excepcionar, de forma tal de evitar los abusos derivados de plantear el instituto en los casos de incumplimientos mínimos o de poca importancia.

d.- El pacto comisorio: Se llama pacto comisorio a la convención por la cual las partes acuerdan resolver el contrato en caso de incumplimiento de una de ellas, abriendo por lo tanto la posibilidad de solicitar directamente daños y perjuicios.

Tradicionalmente, la procedencia del pacto comisorio estaba sujeta a la expresa manifestación de las partes en tal sentido. Así, en el derecho romano el principio era que las partes solo podía solicitar el cumplimiento del contrato, para resolver el acuerdo era necesario asimismo la existencia de una cláusula expresa en tal sentido.

Similar era la inteligencia del código civil argentino en su art. 1204, hasta la reforma del decreto ley 17711/68. El nuevo art. 1204 prevé dos situaciones que legisla separadamente: Que el pacto comisorio haya sido expresamente establecido y los casos en que se omitió, en cuyo hipótesis se considera que el mismo se encuentra incluido en forma tácita.

En el pacto comisorio tácito, ocurrido el incumplimiento, la otra parte debe intimar al cumplimiento de la obligación por un plazo no inferior a los quince días, con más los daños y perjuicios derivados del incumplimiento, plazo que vencido habilita a resolver sin más las obligaciones emergentes del contrato, con derecho al resarcimiento de daños y perjuicios.

Debe tenerse en cuenta que el plazo de quince días puede acortarse en los casos en que se haya pactado un plazo diferente (vg. si se determinó que todos los plazos de un contrato serán de 72 horas desde recibida la notificación).

En cambio el pacto comisorio expreso no es necesaria la intimación previa para resolver el mismo: El tercer párrafo del art. 1204 establece que el mismo producirá efectos desde la manifestación de la parte comunicada en forma fehaciente.

Respecto a la forma de comunicación, si bien el código no establece formas solemnes debemos tener en cuenta que toda vez que es necesaria fecha cierta tanto para establecer el plazo de intimación como la propia resolución del contrato, la comunicación debe hacerse en forma fehaciente, utilizándose en la práctica una carta documento.

Respecto de los efectos del pacto, el contrato queda sin efectos retroactivamente, debiendo las partes devolverse lo que hubieran recibido en función del mismo, teniendo asimismo la parte que ha cumplido derecho a ser resarcida por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento.

Asimismo es necesario analizar en los casos en que ambas partes ya incurrido en culpa. En tal caso, el juez puede declarar el contrato resuelto pero no otorgar daños y perjuicios a ninguna de las partes. Sin embargo, es posible que la culpa de las partes no sea equivalentes (vg. que una sea sólo un incumplimiento parcial contra otro total) en cuyo caso el juez puede establecer una indemnización reducida en beneficio de una de ellas.

Por último debe tenerse en cuenta que la declaración de resolución de contrato mediante el pacto comisorio impide exigir el cumplimiento del contrato, toda vez que el mismo ya se encuentra resuelto.